

NURUL IZMA SHAMIRA BINTI OTHMAN – PERAYU PERTAMA
NORIZAN BINTI ROSLI – PERAYU KEDUA

lwn

CHE KU NA'IM BIN CHE KU RAHIM – RESPONDEN PERTAMA
NORIDAH BINTI MOHAMED NOOR – RESPONDEN KEDUA
MOHAMMAD HATTA BIN MAHMUD – RESPONDEN KETIGA

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 20 April 2022 bersamaan 18 Ramadan 1443H]

Kes No. 10000-083-0004-2019

[Rayuan Hak Jagaan Anak Tak Sah Taraf di bawah seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : Encik Wan Amir Akram bin Dato' Zainal Abidin
: Puan Ainul Fatimah binti Md Hilman
(Tetuan Amir & Elly)

Peguam Syarie Responden 1 : -

Peguam Syarie Responden 2 dan 3 : Puan Yusmawati binti Ab Llah
(Tetuan Yusma & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Perayu-Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 26/06/2020 terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Negeri Selangor yang dikeluarkan

pada 16/06/2020 dalam kes Mal No. 10200-083-0004-2019 sebagaimana berikut :

1. Mahkamah mengisytiharkan bahawa anak bernama Muhammad Iman Rayyan bin Abdullah (No. Sijil Kelahiran : DH 89917 /No. Mykid : 160630-07-0015) adalah seorang anak tak sah taraf.
2. Mahkamah mengisytiharkan bahawa anak bernama Muhammad Iman Rayyan bin Abdullah (No. Sijil Kelahiran : DH 89917 /No. Mykid : 160630-07-0015) adalah anak kandung kepada Plaintiff 1.
3. Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan anak bernama Muhammad Iman Rayyan bin Abdullah (No Sijil Kelahiran : DH 89917/No. Mykid : 160630-07-0015) diberikan kepada Defendan 2 dan Defendan 3.
4. Plaintiff 1 dan Plaintiff 2 hendaklah diberikan hak **melawat tanpa bermalam dengan anak tersebut pada setiap hari Sabtu dan Ahad** di kediaman Defendan 2 dan Defendan 3 di No. 37 Jalan Puncak Bayu 1 Taman Pulai Bayu Skudai 81300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim atau di mana lokasi yang dipersetujui oleh pihak-pihak dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Defendan-Defendan atau mana-mana Defendan sehari sebelum lawatan tersebut.
5. Plaintiff 1 dan Plaintiff 2 **dibenarkan bermalam dengan anak tersebut pada setiap minggu pertama setiap** bulan dengan cara pihak Defendan 2 dan Defendan 3 diperintahkan menyerahkan anak tersebut kepada Plaintiff 1 di Lot 2633-29 Jalan Gombak

Batu 7 $\frac{3}{4}$ Kampung Sungai Cincin, 53100 Gombak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Jumaat dan diambil kembali pada hari Ahad jam 6.00 petang.

6. **Plaintif 1 dan Plaintif 2 dibenarkan bermalam dengan anak tersebut pada setiap minggu ketiga setiap bulan** dengan cara pihak Plaintif 1 atau Plaintif 2 mengambil anak tersebut di kediaman Defendan 2 dan Defendan 3 atau mana-mana lokasi yang dpersetujui bersama sebelum atau pada jam 6.00 petang hari Jumaat dan dipulangkan kembali pada hari Ahad jam 6.00 petang.
7. Mahkamah memerintahkan **hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari perayaan secara bergilir-gilir setiap tahun** antara Defendan dan Plaintif. Bermula pada tahun 2021 (1442H) Plaintif 1 dan Plaintif 2 akan bersama anak tersebut pada Hari Raya Aidilfitri, manakala Defendan 2 dan Defendan 3 akan bersama dengan anak tersebut pada Hari Raya Aidiladha. Pada tahun 2022 (1443H), Defendan 2 dan Defendan 3 akan bersama dengan anak tersebut pada Hari Raya Aidilfitri, manakala Plaintif 1 dan/atau Plaintif 2 akan bersama dengan anak tersebut pada Hari Raya Aidil adha. Begitulah giliran seterusnya dijalankan berselang seli setiap tahun.
8. Defendan 2 atau Defendan 3 diperintahkan menyerahkan anak tersebut kepada Plaintif 1 di Lot 2633-29 Jalan Gombak Batu 7 $\frac{3}{4}$ Kampung Sungai Cincin, 53100 Gombak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sehari sebelum perayaan selewat-lewatnya jam 10.00 pagi dan diambil kembali pada hari raya ketiga seawal jam 6.00 petang.

9. Defendan 2 dan/atau Defendan 3 ditegah daripada menghalang dan/atau membuat apa-apa tindakan yang boleh dianggap sebagai menghalang proses penyempurnaan hak melawat, hak bersama dan hak bermalam oleh Plaintiff 1 dan/atau Plaintiff 2 dengan anak tersebut.
10. Defendan 2 dan/atau Defendan 3 atau agennya atau wakilnya dilarang atau ditegah daripada membawa anak tersebut keluar Malaysia melainkan mendapat keizinan bertulis daripada pihak Plaintiff 1.
11. Mahkamah memerintahkan passport anak bernama Muhammad Iman Rayyan bin Abdullah [No Sijil Kelahiran : DH 89917/No. Mykid : 160630-07-0015] hendaklah dikembalikan kepada Defendan 2 dan atau Defendan ketiga.
12. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan/atau Jabatan Imigresen Malaysia dan/atau Pihak Berkuasa yang berkaitan hendaklah memastikan perintah ini dapat dilaksanakan dengan baik.
13. Mahkamah memerintahkan perintah sementara hadhanah melalui permohonan no : 10200-038-0569-2019 hendaklah dibatalkan.

[2] Daripada keseluruhan terma-terma perintah di atas dan bagi maksud rayuan ini, Perayu-Perayu hanya merayu terhadap lima (5) terma iaitu terma **3,4,6,7 dan 12** namun hanya terma 3 sahaja yang diujahkan.

[3] Responden 2 dan 3 pula telah memfailkan Rayuan Balas melalui Notis Rayuan Balas bertarikh 08/07/2020 yang merayu supaya perintah Yang Arif Hakim Bicara pada terma **4,5,6,7** diubah sebagaimana berikut :

- 3.1 Bahawa **Terma 4** Penghakiman tersebut diubah bahawa Plaintiff Pertama dan Plaintiff Kedua hendaklah diberikan **hak melawat tanpa bermalam** dengan anak tersebut pada **hari Jumaat dan Sabtu** (Cuti hujung minggu Negeri Johor jatuh pada hari Jumaat & Sabtu) setiap hujung minggu pertama setiap bulan di kediaman Defendan Kedua dan Defendan Ketiga di No.37, Jalan Puncak Bayu, Skudai, 81300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada pihak Defendan-Defendan atau mana-mana Defendan sehari sebelum lawatan tersebut.
- 3.2 Bahawa **Terma 5** Penghakiman tersebut diubah bahawa Plaintiff Pertama dan Plaintiff Kedua dibenarkan bermalam dengan anak tersebut pada **setiap hujung minggu ketiga** setiap bulan dengan cara pihak Defendan Kedua dan/atau Defendan Ketiga diperintahkan menyerahkan anak tersebut kepada Plaintiff Pertama di Lot 2633-29 Jalan Gombak Batu 7 $\frac{3}{4}$ Kampung Sungai Cincin, 53100 Gombak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur **sebelum atau pada jam 6 petang hari Jumaat** dan anak tersebut diambil oleh Defendan Kedua dan/atau Defendan Ketiga di kediaman Plaintiff Pertama di Lot 2633-29 Jalan Gombak Batu 7 $\frac{3}{4}$ Kampung Sungai Cincin, 53100 Gombak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada **hari Sabtu selewat-lewatnya pada jam 6 petang**.

- 3.3 Bahawa **Terma 6** Penghakiman tersebut dibatalkan.
- 3.4 Bahawa **Terma 7** Penghakiman tersebut diubah bahawa hak bersama dan bermalam dengan anak tersebut pada hari perayaan bergilir-gilir setiap tahun antara pihak Defendan Kedua dan Defendan Ketiga dan Pihak Plaintiff-Plaintif **bermula pada hari raya tahun 2023 bersamaan 1444H**, Pihak Plaintiff Pertama akan bersama anak tersebut pada hari raya Aidilfitri 2023 manakala Pihak Defendan Kedua dan Ketiga akan bersama anak tersebut pada hari raya Aidil Adha 2023. Pada tahun 2024 (1445H), Pihak Defendan Kedua dan Pihak Defendan Ketiga akan bersama anak tersebut di hari raya Aidilfitri manakala Pihak Plaintiff Pertama dan Kedua akan bersama anak tersebut pada hari raya Aidil Adha dan begitulah giliran seterusnya dijalankan berselang seli setiap tahun.
- 3.5 Bahawa Pihak Plaintiff Pertama dan Plaintiff Kedua diperintahkan mengambil anak tersebut di kediaman Defendan Kedua dan Defendan Ketiga di No.37, Jalan Puncak Bayu, Skudai, 81300 Johor Bahru, Johor Darul Takzim sehari sebelum perayaan selewatnya jam 10 pagi dan Defendan Kedua dan Defendan Ketiga akan mengambil anak tersebut di kediaman Pihak Plaintiff Pertama di Lot 2633-29 Jalan Gombak Batu 7 $\frac{3}{4}$ Kampung Sungai Cincin, 53100 Gombak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada hari raya kedua sebelum jam 6 petang.
- 3.6 Bahawa **Terma 7** Penghakiman tersebut dibatalkan dan/atau sebagai alternatif diubah bahawa pihak Plaintiff Pertama dan Kedua dan/atau agennya dan atau wakilnya dilarang atau ditegah

membawa anak tersebut keluar daripada Malaysia melainkan dengan persetujuan Defendan Kedua dan Ketiga.

FAKTA KES

[4] Perayu Pertama dalam kes ini adalah ibu kandung kepada Muhammad Iman Rayyan bin Abdullah [No Sijil Kelahiran : DH 89917/No. Mykid : 160630-07-0015] (selepas ini dikenali sebagai '*anak tersebut*') iaitu anak yang menjadi pertikaian dalam kes ini. Manakala Perayu Kedua pula adalah ibu kepada Perayu Pertama dan nenek kepada anak tersebut.

[5] Responden Pertama pula adalah suami kepada Perayu Pertama dan bapa biologi kepada anak tersebut. Manakala Responden Kedua dan Ketiga pula merupakan pasangan warganegara Singapura yang menetap di Johor Bahru dan telah menjaga anak tersebut selepas kira-kira tiga dilahirkan.

[6] Perayu Pertama dan Responden Pertama telah berkahwin pada 17/04/2017 di Setapak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur iaitu selepas kelahiran anak tersebut iaitu pada 30/06/2016. Pihak-pihak tiada pertikaian berkaitan status anak tersebut sebagai anak tidak sah taraf.

[7] Anak tersebut telah berada dalam jagaan dan kawalan Responden Kedua dan Ketiga sejak 02/07/2016 apabila didakwa berlakunya isu pemerdagangan bayi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

[8] Pada 16/01/2018 Perayu-Perayu telah memfailkan tuntutan hak jagaan bagi menuntut anak tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui kes Mal No : 10200-083-0043-2018 dengan menamakan Responden-Responden sebagai Defendan-Defendan pada waktu itu. Lanjutan daripada

tuntutan tersebut, pada 21/02/2018 Mahkamah telah memutuskan hak jagaan anak tersebut diberikan kepada Perayu Pertama.

[9] Tidak berpuashati dengan keputusan serta perjalanan prosiding tersebut, Responden Kedua dan Ketiga telah memfailkan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah melalui kes Permohonan Semakan No: 10000-003-0032-2018. Pada 13/07/2018 Panel Rayuan secara sebulat suara membenarkan semakan tersebut dengan membatalkan perintah bertarikh 21/02/2018 dan memerintahkan kes dibicarakan semula akibat kegagalan Mahkamah Bicara mengambil keterangan Responden-Responden. Bagi tujuan perbicaraan semula, kes asal no : 10200-083-0043-2018 telah diberikan nombor kes baru yang mana sebahagian keputusannya sebagaimana pada perenggan [1] dirayu di hadapan kami.

[10] Pada peringkat rayuan ini, Perayu-Perayu serta Responden Kedua dan Ketiga masing-masing telah memfailkan hujahan bertulis secara serentak pada 05/11/2021. Manakala Responden Pertama telah bersetuju dengan rayuan Perayu-Perayu sebagaimana Afidavit Persetujuan yang diikrarkan pada 22/09/2021 dan tidak memfailkan apa-apa hujahan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Rayuan Balas, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Perbicaraan. Setelah penelitian dibuat kami mendapati isu-isu yang dibangkitkan di hadapan kami adalah menjurus kepada dua isu utama sahaja yang perlu diputuskan iaitu :

- 11.1 Sama ada Responden Kedua dan Ketiga mempunyai *locus standi* terhadap hak penjagaan anak tersebut.
- 11.2 Sama ada seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen*] memberikan hak mutlak kepada Perayu-Perayu untuk mendapat hak jagaan anak tersebut atau masih tertakluk kepada pertimbangan dan pengecualian lain.

Isu Pertama

[12] Bagi isu yang pertama Perayu-Perayu menghujahkan bahawa Responden Kedua dan Ketiga tidak mempunyai *locus standi* terhadap hak penjagaan anak tersebut sebagaimana Tuntutan Balas bertarikh 12/03/2019. Hal ini kerana kedua-duanya tidak mempunyai sebarang hubungan darah dan persemendaan serta bukanlah warganegara Malaysia atau berstatus Penduduk Tetap yang diberi kuasa oleh mana-mana undang-undang atau apa-apa kebenaran khas bagi mengemukakan apa-apa permohonan kepada pihak berkuasa untuk mengawal dan/atau menjaga anak tersebut.

[13] Selain itu turut diujahkan bahawa kedua-dua Responden juga secara dasarnya tidak akan diiktiraf sebagai ibu dan bapa angkat anak tersebut memandangkan Akta Pengangkatan 1952 [Akta 253] menghalang seseorang kanak-kanak warganegara ini diberi pengangkatan kepada mana-mana individu atau pasangan yang berstatus bukan warganegara dan/atau Penduduk Tetap. Oleh itu Perayu-Perayu turut menyatakan bahawa dengan mengekalkan hak jagaan anak tersebut kepada Responden-Responden hanya akan membuka ruang yang lebih luas kepada berlakunya jenayah sendiket pemerdagangan kanak-kanak dan telah menyalahgunakan proses mahkamah.

[14] Responden Kedua dan Ketiga pula menghujahkan bahawa isu *locus standi* yang dibangkitkan adalah *res judicata*. Ini kerana Panel Mahkamah Rayuan Syariah pada 13/07/2018 melalui Permohonan Semakan No. 10000-003-0032-2018 telah membatalkan perintah hak jagaan sebelum ini dan memerintahkan kes dibicarakan semula. Asas utama kepada keputusan tersebut adalah Mahkamah Bicara tidak mengambil kira keterangan kedua-dua Responden sebelum keputusan dibuat demi keadilan semua pihak yang berkepentingan.

[15] Bagi memutuskan isu ini sukacita untuk kami menjelaskan prinsip *locus standi* dalam perundangan terlebih dahulu. Terma latin ini secara ringkasnya bermaksud hak untuk membawa sesuatu kes ke Mahkamah ataupun hak untuk dibicarakan di Mahkamah. Ia juga merujuk kepada hak untuk mendakwa atau menuntut dan hak untuk didakwa atau dituntut. Prinsip ini secara asasnya adalah bertepatan dengan kaedah fiqh yang meletakkan beban membuktikan sesuatu itu adalah keatas orang yang mendakwa. Ini bermakna seseorang yang ingin mendakwa atau menuntut sesuatu perlulah membuktikan mempunyai hak dan kepentingan dalam tuntutan tersebut.

[16] Dalam kes *Ervin Ahabovic lwn Amalya Evelyn Abdullah [2013] 1 CLJ (Sya)*, Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan semasa mengulas mengenai *locus standi* antara lain menyatakan :

Locus standi adalah hak seseorang untuk memulakan pembicaraan di mahkamah. Dalam kes di England, *R v. Commissioner of Police for the Metropolis exp. Blackburn [1973] 1 All ER 324* Lord Denning memutuskan akan menidakkan *locus standi* kepada seseorang penyibuk yang menyentuh hak yang tidak berkaitan dengannya tetapi akan memberikan *locus standi*

kepada sesiapa yang mempunyai isu benar dimana sesuatu yang berlaku atau bakal berlaku mempunyai kesan keatasnya.

[17] Dalam kes *Abdul Razak Ahmad lwn Kerajaan Negeri Johor 1994 3 AMR 2463*, YA Hakim telah menyatakan bahawa pertimbangan untuk membuktikan *locus standi* Plaintiff mesti melakukan tiga perkara:

- i. Plaintiff ada hak yang diiktiraf di bawah undang-undang
- ii. Hak plaintiff itu telah dilanggar atau dinodai; dan
- iii. Plaintiff telah mengalami mudarat disebabkan pelanggaran haknya itu.

[18] Dalam konteks tuntutan penjagaan anak, mana-mana pihak yang berkepentingan dalam penjagaan anak boleh dianggap mempunyai kausa tindakan untuk menuntut hak jagaan anak. Oleh yang demikian secara prinsipnya kuasa mutlak untuk menjaga anak-anak tidak semestinya terletak pada ibu atau bapa atau saudara tetapi termasuk juga pihak ketiga atau badan-badan tertentu jika didapati kemungkinan kebajikan anak-anak akan terjejas.

[19] Merujuk kepada fakta dalam kes ini, kami dapati anak tersebut telah berada dalam kawalan dan jagaan pihak Responden Kedua dan Ketiga sejak 02/07/2016 iaitu kira-kira tiga hari selepas dilahirkan sehingga prosiding di Mahkamah Bicara. Walau apa pun punca dan cara anak tersebut diserahkan kepada pihak Responden Kedua dan Ketiga namun pada hemat kami fakta ini sahaja sudah cukup untuk memberikan *locus standi* kepada kedua-dua Responden setakat sebagai pihak yang berkepentingan yang mempunyai hak untuk keterangan berkaitan hak penjagaan anak tersebut didengari.

[20] Hal ini adalah selaras dengan keputusan yang dibuat oleh Panel Rayuan Syariah pada 13/07/2018 semasa membenarkan semakan yang dibuat oleh Responden-Responden Kedua dan Ketiga sebagaimana yang diujahkan oleh kedua-dua Responden. Dalam keputusan tersebut, semakan telah diterima dengan alasan Mahkamah Bicara telah tidak mengambil kira keterangan kedua-dua Responden sebelum membuat keputusan. Oleh yang demikian pada hemat kami secara tersiratnya kedua-dua Responden mempunyai ruang untuk memberikan keterangan yang membawa kepada kesimpulan bahawa kedua-duanya mempunyai *locus standi*.

Isu Kedua

[21] Bagi isu yang kedua pula, Perayu-Perayu mengujahkan bahawa seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 secara harfiahnya (*literal*) meletakkan hak penjagaan bagi anak tak sah taraf adalah semata-mata kepada ibu dan saudara mara ibu. Menurut Perayu-Perayu juga peruntukan ini tidak boleh ditafsir dengan meletakkan sebarang syarat lain. Oleh yang demikian Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf apabila mengambil kira pendekatan lain seperti membandingkan taraf kehidupan antara Perayu-Perayu dengan Responden Kedua dan Ketiga dalam menentukan hak jagaan anak tersebut.

[22] Manakala Responden Kedua dan Ketiga pula mengujahkan bahawa faktor kebajikan anak tersebut merupakan pertimbangan utama yang perlu diambil kira oleh Mahkamah melangkaui kemahuan pihak-pihak yang bertelingkah dan kedudukan nasab Perayu-Perayu dengan anak tersebut. Hujahan kedua-dua Responden ini adalah berdasarkan peruntukan seksyen 87(1) dan (2) Enakmen.

[23] Selain itu kedua-dua Responden turut berhujah bahawa pemakaian seksyen 86 adalah hak mutlak kepada Perayu-Perayu tanpa mengambil kira pertimbangan lain adalah dalam situasi anak tersebut telah berada dalam jagaan Perayu-Perayu sejak dari awal kelahiran lagi. Maka dalam keadaan sebeginilah Perayu Pertama selaku ibu kandung adalah lebih berhak kepada anak tak sah taraf tersebut. Namun berbeza dengan kes ini dimana Perayu telah menyerahkan anak tersebut kepada pihak ketiga sejak berusia tiga hari.

[24] Menurut kedua-dua Responden, dalam keadaan sebegini kebajikan anak adalah perkara paling utama yang sepatutnya diberi pertimbangan berbanding pertalian nasab. Sungguhpun tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak tersebut serta merupakan warganegara Singapura, namun kedua-dua Responden menyatakan telah menjaga anak tersebut dengan sebaiknya.

[25] Bagi memutuskan isu ini kami telah merujuk kepada peruntukan seksyen 86 Enakmen yang menyatakan :

Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sahtaraf

Penjagaan kanak-kanak tak sahtaraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu.

Peruntukan ini merupakan status quo undang-undang bagi penjagaan seseorang kanak-kanak yang tak sah taraf yang memberi maksud secara prinsipnya hak jagaan perlu diberikan kepada ibu kandung. Walau bagaimanapun pada hemat kami pemakaiannya turut bergantung kepada fakta bagaimana anak tersebut dibesarkan selepas dilahirkan.

[26] Fakta yang dibentangkan di hadapan kami menunjukkan anak tersebut telah berada dalam jagaan dan kawalan Responden Kedua dan Ketiga sejak berumur tiga hari lagi. Sejak itu kedua-dua Responden telah memberikan

kasih sayang, menyediakan tempat tinggal dan memberikan pendidikan kepada anak tersebut. Kewujudan fakta-fakta ini dengan sendirinya telah menimbulkan persoalan kepada kami berkaitan kebajikan kanak-kanak tersebut terutamanya dari sudut psikologi, emosi dan keselamatan sekiranya berpindah jagaan. Dalam situasi sebegini isu kelayakan dan kebajikan sebagaimana kehendak seksyen 83 dan 87 Enakmen perlu diberi perhatian. Kedua-dua seksyen tersebut memperuntukkan sebagaimana berikut :

Seksyen 83. Kelayakan-kelayakan yang perlu untuk penjagaan

Seseorang yang mempunyai hak mendidik seseorang kanak-kanak, adalah berhak menjalankan hak terhadap hadhanah jika—

- (a) dia adalah seorang Islam;*
- (b) dia adalah sempurna akal;*
- (c) dia berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu;*
- (d) dia berkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah; dan*
- (e) dia tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak atau jasmani.*

Seksyen 87. Kuasa Mahkamah membuat perintah mengenai penjagaan

(1) Walau apa pun peruntukan seksyen 83, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan perintah memilih untuk meletakkan seseorang kanak-kanak dalam jagaan salah seorang daripada orang-orang yang tersebut di dalam seksyen itu atau, jika ada hal keadaan yang luar biasa yang menyebabkan tidak diingini bagi kanak-kanak itu diamanahkan kepada salah seorang daripada orang-orang itu, Mahkamah boleh dengan perintah meletakkan kanak-kanak itu dalam jagaan mana-mana orang lain atau mana-mana persatuan yang tujuan-tujuannya adalah termasuk kebajikan kanak-kanak.

(2) Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan, tertakluk kepada pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) kemahuan-kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan

(b) kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya sendiri.

[27] Dalam hal ini kami bersetuju dengan dapatan Yang Arif Hakim Bicara sebagaimana yang dijelaskan dalam alasan penghakimannya pada halaman 120 Rekod Rayuan iaitu :

[40] Mahkamah berpendapat seksyen 86 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) yang memperuntukkan bahawa penjagaan anak tak sah taraf adalah semata-mata pada ibu dan saudara mara ibu jika mereka berkelayakan dan boeh menjaga kebajikan terbaik anak tersebut.

[28] Dengan hormatnya kami turut bersetuju dan sedia maklum tentang kes-kes yang menjadi sandaran autoriti oleh Perayu-Perayu. Walau bagaimanapun pada hemat kami ianya adalah berbeza dengan kes di hadapan kami ini. Kes-kes tersebut melibatkan perebutan anak tidak sah taraf antara ibu kandung dan bapa biologi. Berbeza dengan kes ini dimana ianya melibatkan pertikaian antara ibu kandung dengan pihak ketiga yang telah menjaga anak tersebut sejak lahir sehingga sekarang berumur 6 tahun.

[29] Sukacita juga untuk ditegaskan apabila kami menyatakan bahawa pertimbangan hak jagaan adalah berdasarkan kepada kebajikan kepada anak tersebut ianya bukanlah bermakna telah membelakangkan ketetapan Syarak dari sudut pertalian nasab antara Perayu-Perayu dengan anak tersebut. Ini

kerana menurut Syarak soal kebajikan anak itu sendiri adalah perkara yang paling asas dan sangat dititik beratkan dalam menentukan hak jagaan.

[30] Bagi memperkukuhkan pandangan kami berkaitan isu kebajikan ini, kami kemukakan beberapa autoriti nas Syarak sebagai panduan antaranya Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 8 semasa menjelaskan tentang konsep hadhanah antara lain kami petik :

إن لكل من الحاضنة والمحضون حقاً في الحضانة ، إلا أن حق المحضون أقوى من حق الحاضنة

“Sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga (anak) mempunyai hak di dalam hal pemeliharaan tetapi hak yang yang dijaga (anak) lebih kuat daripada hak yang menjaga.”

[31] Manakala dalam kitab ‘*Al-fiqh al-Muqarran lil ahwal syakhsiyyah*’ oleh Badran Abdul Ainami, juzuk 1, halaman 543 hingga 544 pula menyatakan :

غاية لأمر أن حق الصغير أقوى لأن مصلحته مقدمة على مصلحه ابويه وأنه يجب العمل بما هو انفع
واصلح للصغير في باب الحضانة

“ Tujuan hadhanah adalah ditujukan kepada anak itu dan hak anak adalah lebih utama kerana kebajikan adalah didahulukan dari kebajikan kedua ibubapanya. Mengutamakan kebajikan anak adalah dimestikan kerana dengan itu akan dapat mencapai perkara yang terbaik lagi elok untuk anak itu dalam bab hadhanah.”

[32] Prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam nas-nas di atas kami dapati telah diaplikasi dalam kes-kes yang pernah diputuskan antaranya dalam kes *Nooranita bte Kamaruddin lwn. Faeiz bin Yeop Ahmad [1989] 2 MLJ*. Dalam kes ini Hakim bicara telah memberi panduan berkenaan pertimbangan memelihara kebajikan kanak-kanak apabila menyatakan :

“...Pertimbangan utama yang terpakai dalam semua kes-kes hadhanah ialah hak kanak-kanak yang dipertikaikan mestilah diberikan keutamaan daripada hak orang yang menuntut hadhanah kerana tujuan hadhanah itu sendiri ialah untuk kebajikan kanak-kanak dan bukanlah untuk kebajikan pihak-pihak yang bertelingkah.”

[33] Begitu juga dalam kes ***Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob***, JH Jilid 17 Bhg 1 muka surat 247, Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan pada ketika itu telah membuat dapatan bahawa :

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[34] Autoriti-autoriti di atas menunjukkan hak jagaan atau hadanah adalah berkait rapat dengan kepentingan kanak-kanak. Oleh itu sekiranya terdapat sebarang pertentangan hak antara kedua ibu bapa atau mana-mana pihak yang berkepentingan, ianya bukanlah menjadi hak eksklusif kepada mana-mana pihak sebaliknya hak kanak-kanak mesti diutamakan dari yang lain. Berasaskan kepada dapatan ini, sebarang keputusan membabitkan kanak-kanak perlu melihat kepada apa yang paling mendatangkan kebaikan kepada kanak-kanak secara keseluruhan atau yang disebut sebagai prinsip kebajikan kanak-kanak (*the welfare of the child*) atau kepentingan terbaik kanak-kanak (*the best interests of the child*).

[35] Pemerhatian kami secara menyeluruh terutamanya kepada peruntukan-peruntukan sekyen 83 dan 87 Enakmen telah menggambarkan penekanan yang diberikan oleh undang-undang keluarga Islam terhadap kebajikan kanak-kanak dan bukannya pemilikan ibu bapa atau mana-mana penjaga terhadap anak-anak. Hak-hak mereka yang diperuntukkan berkenaan kanak-kanak adalah dalam kerangka memenuhi tuntutan kebajikan kanak-kanak itu sendiri.

Dalam konteks rayuan ini kami berpandangan bahawa kebajikan anak tersebut adalah faktor yang melangkaui status dan kedudukan nasab Perayu-Perayu.

[36] Berdasarkan kepada nas undang-undang serta autoriti yang kami telah nyatakan juga menunjukkan pertimbangan kebajikan dalam menentukan hak jagaan adalah prinsip yang telah mantap dan bersifat umum yang turut merangkumi anak tak sah taraf. Oleh yang demikian peruntukan seksyen 86 tidaklah boleh dianggap berdiri dengan sendiri sebaliknya turut bergantung kepada soal-soal kelayakan dan kebajikan yang perlu diberi pertimbangan utama. Ini bermakna peruntukan tersebut juga tidaklah secara mutlak memberikan hak kepada Perayu-Perayu dalam mendapatkan hak jagaan anak.

[37] Dengan mengambil kira penjagaan dan kawalan anak tersebut oleh kedua-dua Responden sejak berumur tiga hari sehingga sekarang telah berumur kira-kira enam tahun merupakan suatu tempoh yang agak lama. Pada hemat kami bagi mengelakkan sebarang kemudaran dari sudut emosi dan mental serta menjejaskan pendidikan awal dan tumbesaran kanak-kanak tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar untuk berpindah hak jagaan. Dalam hal ini kami merujuk kepada seksyen 87(3) yang memperuntukkan :

(3) Adalah menjadi suatu anggapan yang boleh dipatahkan bahawa adalah untuk kebaikan seseorang kanak-kanak dalam masa dia kecil supaya berada bersama ibunya, tetapi pada memutuskan sama ada anggapan itu dipakai bagi fakta-fakta sesuatu kes tertentu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada tidak baiknya mengacau kehidupan seseorang kanak-kanak dengan bertukar-tukarnya jagaan.

[38] Bagi memperkukuhkan pandangan ini dengan hormatnya kami merujuk keputusan yang dibuat oleh Jemaah Pengadilan dalam kes *Wan Abdul Aziz Iwn Siti Aishah (1975) 1 JH 47* yang berpendapat jiwa anak yang telah

tinggal dan diasuh oleh nenek sebelah bapanya selama lebih kurang satu tahun akan tersentuh jika dipisahkan. Lebih-lebih lagi tidak ada keterangan yang menunjukkan kebajikan atau masalah kanak-kanak tersebut akan terjejas dalam pemeliharaan neneknya dan dijaga serta diawasi oleh bapanya.

[39] Sungguhpun begitu pada hemat kami hubungan antara Perayu-Perayu dengan anak tersebut selaku ibu dan nenek kandung hendaklah sentiasa dijalinan dan tidak boleh sama sekali diputuskan sebagaimana tuntutan Syarak. Firman Allah SWT dalam ayat 23 Surah Al-isra' :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَنْتَغَنَّ مِنَ الْكِتَابِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "ah", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun).”

Bagi memastikan ruh dan semangat dalam ayat tersebut dapat dicapai maka suatu mekanisme hak lawatan yang bersesuaian perlu ditetapkan disamping perintah-perintah sedia ada sehingga berlakunya apa-apa perubahan matan yang memungkinkan perubahan perintah dibuat.

Rayuan Balas

[40] Merujuk kepada Notis Rayuan Balas, Responden Kedua dan Ketiga merayu agar perintah Yang Arif Hakim Bicara pada terma 4,6,7 dan 12 yang

berkaitan dengan kaedah lawatan, giliran berhari raya dan penyerahan passport anak tersebut diubah.

[41] Setelah penelitian dibuat kepada setiap terma berkaitan kami dapati hujahan kedua-dua Responden hanya memfokuskan kepada terma 4,6 dan 7 sahaja iaitu berkaitan dengan kegagalan Yang Arif Hakim Bicara mengambikira tempoh masa bermalam, hari melawat serta jarak perjalanan antara Kuala Lumpur dan Johor Bahru yang terpaksa dilalui oleh kedua-dua Responden dan Perayu-Perayu. Menurut kedua-dua Responden keadaan ini menyebabkan kesukaran untuk dilaksanakan dengan berkesan. Tiada sebarang hujahan daripada Perayu-Perayu berkaitan isu-isu yang dibangkitkan dalam rayuan balas ini.

[42] Pada hemat kami dengan mengambil kira faktor-faktor yang dinyatakan oleh kedua-dua Responden, maka suatu aturan masa dan kaedah lawatan yang bersifat lebih fleksibel dan praktikal perlu ditetapkan selaras dengan kehendak seksyen 88(2)(d) yang memperuntukkan :

memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; ...

[43] Oleh yang demikian perintah-perintah berkaitan dengan hak lawatan yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara memerlukan campur tangan kami untuk dibuat penilaian semula. Hal ini bagi memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan serta menjamin hubungan Perayu-Perayu dan anak tersebut sentiasa terjalin. Perlaksanaan hak jagaan dan lawatan ini tidak dapat tidak memerlukan komitmen, kerjasama dan pengorbanan

daripada kedua-dua pihak agak kemaslahatan dan kebajikan anak tersebut sentiasa terjaga.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rayuan Balas dan penghujahan kedua-dua pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan dan memerintahkan sebagaimana yang berikut:-

1. Bahawa rayuan Perayu-Perayu adalah **DITOLAK**.
2. Bahawa rayuan balas Responden Kedua dan Ketiga **DITOLAK**.
3. Bahawa Perintah Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor bagi terma 4,5 dan 6 dalam kes Mal No. 10200-083-0004-2019 bertarikh 16/06/2020 **DIPINDA** kepada :
 - 3.1 Plaintiff 1 dan Plaintiff 2 diberi hak untuk melawat, bersama dan bermalam dengan anak tersebut setiap dua minggu sekali pada setiap bulan mulai jam 6.00 petang hari Jumaat sehingga jam 6.00 petang hari Sabtu pada mana-mana minggu yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak dengan cara Defendan 2 dan Defendan 3 menghantar anak tersebut ke kediaman semasa Plaintiff-Plaintif.
 - 3.2 Defendan Kedua dan/atau Ketiga hendaklah memaklumkan kepada Plaintiff-Plaintif atau mana-mana Plaintiff sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum lawatan dilaksanakan.
4. Bahawa terma 3, 7, 8,11 dan 12 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATO' MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor